

NOR RASHIDAH BT ZAKARIAH

lawan

AFIF BIN AMINUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 13hb Julai 2021 / 3 Zulhijjah 1442H

Kes Rayuan No. 10000-003-0069-2021

[Semakan Terhadap Perintah Interim Hak Jagaan Anak]

Peguam Syarie Pemohon : -

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Pemohon memfailkan permohonan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut :

- i. ,Bahawa suatu semakan dibuat terhadap keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes saman no. 10100-028-0119-2019;

- ii. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini membatalkan Perintah bertarikh 28/4/2021 dalam kes saman no. 10100-028-0119-2019;
- iii. Bahawa perintah ini berkuatkuasa sehingga perintah hak jagaan kekal kes saman no. 10100-028-0119-2019 diputuskan;
- iv. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan kes saman no. 10100-028-0119-2019 hendaklah dibicarakan semula dihadapan Hakim yang lain.
- v. Apa-apa relief yang patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Mulai ini.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden di dalam tempoh perkahwinan mereka telah dikurniakan dengan seorang anak iaitu Nur Airis Safiya binti Afif yang berusia 7 tahun (selepas ini disebut sebagai anak tersebut). Pemohon dan Responden telah bercerai pada 5/5/2017.

[3] Pada 1/2/2019, Responden telah memfailkan tuntutan hak jagaan kekal anak tersebut melalui kes saman no. 10100-028-0119-2019 dan masih diperingkat perbicaraan.

[4] Pada 18/6/2020 pula, Responden telah menfailkan permohonan interim hadhanah secara *inter-parte* di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes

permohonan no. 10400-038-0222-2020 dan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah pada 11/11/2020 telah memerintahkan sebagaimana berikut:-

- a. *Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
- b. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara ke atas anak yang bernama Nur Airis Safiya binti Afif (No. Mykid :141218-10-2552) hendaklah diserahkan kepada Responden (ibu) sehingga kes induk dalam sama no. 10100-028-0119-2019 diputuskan.*
- c. *Mahkamah memerintahkan bahawa Pemohon diberikan hak lawatan, tanpa bermalam dengan anak tersebut pada hari Sabtu minggu pertama, Sabtu minggu kedua dan Sabtu minggu ketiga setiap bulan, bermula dari pukul 9.00 pagi dan dipulangkan pada hari yang sama selewat-lewatnya jam 6.00 petang.*
- d. *Mahkamah memerintahkan bahawa pengambilan dan pemulangan anak adalah di alamat tempat tinggal Responden/ditempat anak itu berada.*
- e. *Mahkamah memerintahkan bahawa Responden atau mana-mana pihak bagi pihak Responden adalah ditegah dari menghalang Pemohon dari melaksanakan hak lawatan ke atas anak tersebut.*

- f. Mahkamah memerintahkan bahawa Responden hendaklah memaklumkan kepada Pemohon jika berlaku perubahan tempat tinggal anak tersebut.*
- g. Mahkamah memerintahkan bahawa sebarang kegagalan mematuhi Perintah ini adalah melakukan suatu penghinaan kepada Mahkamah dan dengan itu boleh dikomitkan ke Penjara.*

[5] Selanjutnya pada 28/4/2021 semasa pendengaran kes hak jagaan induk saman no. 10100-028-0119-2019, Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah yang baru telah mengeluarkan satu perintah sementara yang lain seperti berikut:-

- a. Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bermalam diberikan kepada Plaintiff (bapa) dua kali sebulan pada minggu pertama dan ketiga atau minggu kedua dan keempat. Kalau tidak dapat digantikan pada minggu yang lain.*
- b. Mahkamah memerintahkan cuti persekolahan dibahagi dua dimulakan dengan Plaintiff diakhiri Defendan.*
- c. Mahkamah memerintahkan cuti hari raya bergilir-gilir. Hari Raya ini Plaintiff ambil. Petang raya pulang kepada Defendan.*
- d. Kes tangguh untuk perbicaraan lisan pada 11/10/2021.*

[6] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Bicara pada 28/4/2021 tersebut dan memfailkan permohonan semakan ini. Berdasarkan

kepada Afidavit Permohonan Pemohon hanya terdapat 2 isu sahaja yang dibangkitkan Pemohon bagi menyokong permohonannya iaitu;

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah tidak menimbang secara adil dan berhemah bahawa anak perempuan Pemohon yang bernama Nur Airis Safiya binti Afif (No. Mykid :141218-10-2552) yang berusia 8 tahun adalah memerlukan saya selaku ibu kandungnya untuk menjaga dan tinggal bersamanya kerana sejak dari kecil anak tersebut bersama Pemohon.
- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah mengeluarkan perintah interim yang kedua tanpa Responden memfailkan permohonan yang lengkap, sedangkan sudah ada perintah interim bertarikh 11/11/2020 yang masih berkuatkuasa terhadap anak tersebut.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Secara umumnya permohonan untuk menyemak suatu keputusan interim sama ada secara *inter-parte* atau *ex-parte* yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah adalah merujuk kepada Arahan Amalan No.9 Tahun 2006 sebagaimana berikut:-

....telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa permohonan semakan ke atas keputusan dan perintah ex-parte adalah tidak dibenarkan selagi kes induk masih

belum diselesaikan. Pihak-pihak yang terkilan hendaklah memfailkan Notis Rayuan ke atas kes induk tersebut.

[8] Walaupun Arahan Amalan tersebut menyatakan perintah yang tidak boleh disemak adalah Perintah *ex-parte*, sedangkan kes di hadapan kami ini adalah Perintah Interim yang diputuskan melalui prosiding *inter-parte*, namun prinsip yang harus diberi perhatian ialah tujuan kenapa ia tidak boleh disemak?

[9] Kami bersetuju bahawa Arahan Amalan itu digubal bertujuan untuk mengelakkan perbicaraan kes induk mengambil masa yang lama kerana diganggu oleh sesuatu prosiding permohonan sampingan. Ianya juga di atas prinsip sesuatu perintah interim itu hanya bersifat sementara sahaja sehingga keputusan/perintah muktamad dibuat melalui kes induk.

[10] Di atas prinsip itulah perintah interim *inter-parte* juga tidak dibenarkan disemak **kecuali** jika;

- i. Ternyata berlaku salah aturan yang menjejaskan keadilan; atau
- ii. Sesuatu keputusan tersebut menyalahi hukum syarak yang bersifat qatie (muktamad) dan/atau peruntukkan undang-undang.

[11] Walau bagaimanapun terdapat pengecualian kes-kes interim *inter-parte* ini boleh disemak iaitu apabila ternyata berlaku salah aturan yang menjejaskan keadilan, atau sesuatu keputusan tersebut menyalahi hukum syarak yang bersifat qatie (muktamad) dan/atau peruntukkan undang-undang, sebagaimana kes Mohd

Fauzi bin Yaacoob lwn. Zabedah binti Hanapiah kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0009-2010 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 20/9/2010 (belum dilaporkan) dan kes Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 yang menyatakan seperti berikut:

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[12] Setelah kami meneliti Afidavit Pemohon, kami dapati Pemohon telah mempersoalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah yang bertarikh 28/4/2021 yang didakwa Pemohon, telah khilaf apabila membuat keputusan tanpa mengambil kira telah wujud perintah interim hadhanah dan masih berkuatkuasa. Pemohon juga mempersoalkan tentang permohonan pihak Responden yang dibuat tanpa permohonan yang lengkap dan secara bertulis difailkan ke Mahkamah.

[13] Oleh yang demikian, kami perlu menilai samada keputusan Hakim Bicara tersebut salah aturan yang nyata, berdasarkan undang-undang dan hukum syarak atas alasan permohonan Pemohon tersebut.

[14] Kami memanggil dan menyemak rekod kes mal no. 10400-038-0222-2020 dan rekod kes no. 10100-028-0119-2019, dapatan kami adalah seperti berikut:-

- i. Hakim Bicara telah bertindak mendengar permohonan di dalam prosiding *inter-parte* dengan permohonan interim ini dimulakan oleh Responden pada 18/6/2020. Kemudian Hakim Bicara telah mengeluarkan perintah bertarikh 11/11/2020 seperti di perenggan 4 di atas.
- ii. Semasa pendengaran kes induk hak jagaan di hadapan Hakim Bicara yang baru pada 28/4/2021, Responden telah membangkitkan isu hak lawatan untuk bermalam termasuk hak lawatan semasa cuti sekolah terhadap anak tersebut. Mahkamah arahkan pihak-pihak untuk berbincang tetapi tiada sebarang penyelesaian antara pihak-pihak.
- iii. Disebabkan tiada penyelesaian antara pihak Pemohon dan Responden, Hakim Bicara yang mendengar kes induk hadhanah tersebut telah mengeluarkan perintah seperti di perenggan 5 diatas.
- iv. Pemohon sebagai seorang ibu merupakan orang yang paling layak untuk menjadi hadhinah kepada anak perempuan yang berusia 8 tahun dari segi undang-undang dan hukum syarak kerana sejak dilahirkan sehingga sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon.

[15] Berhubung dengan isu hak jagaan anak, suka kami merujuk kepada subseksyen 82(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enak. No.2/2003*] yang menyatakan:-

Tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.

Ini bermaksud *status-quo* hadhanah seseorang anak yang masih kecil ialah di bawah penguasaan ibunya sehinggalah pihak penentang berjaya membuktikan di Mahkamah bahawa sifat-sifat ibu di masa-masa yang material bertentangan dengan seksyen 83 dan membuktikan hak seseorang perempuan terhadap hadhanah telah hilang sebagaimana kehendak seksyen 84 enakmen yang sama.

[16] Peruntukan ini adalah menepati kehendak hukum syarak. Di dalam kitab *Kifayatul al Akhyar*, karangan Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, (ulama' pengikut mazhab Syafei kurun kesembilan Hijrah), juzuk 2, muka 93, cetakan Sulaiman Marie, Singapura, ada menyebut:-

وهي نوع من الولاية إلا أنها بالإناث أليق، لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام
بها وأشد ملازمة للأطفال، ومؤنة الحضانة على الأب، لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة، فإذا
فارق الرجل زوجته فالأم أحق بحضانة الولد منه، ومن النساء باشرط

Yang bermaksud:

“Hadhanah adalah sejenis kuasa, kecuali atas sebab-sebab yang tertentu, diberi kepada perempuan kerana mereka lebih menaruh kasih sayang kepada kanak-kanak, lebih tepat untuk mendidiknya, lebih sabar dalam

melaksanakan tugas memelihara kanak-kanak dan perempuan juga sentiasa lebih banyak bergaul dengan kanak-kanak. Pembiayaan hadonah tertanggung ke atas bapa kerana pembiayaan hadonah itu adalah diperlukan sama seperti nafkah. Apabila seseorang lelaki bercerai dengan isterinya, ibu (isteri itu) adalah lebih berhak mendapat hak hadonah anak pasangan itu daripada bapa anak itu, dan daripada wanita-wanita yang lain dengan beberapa syarat.”

[17] Keutamaan ibu yang paling layak adalah berdasarkan sebab ibunya lebih menaruh kasih sayang, lebih sabar mendidiknya, membelainya manja, lemah lembutnya, lebih merinduinya dan sebagainya. Kesemua sifat-sifat yang ada pada diri ibu tersebut sebenarnya adalah demi kemaslahatan anak tersebut bukannya kemaslahatan ibu penjaganya. Ini bertepatan konsep hadhanah yang mana dijelaskan oleh Sayed Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 8 :

إن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة ، إلا أن حق المحضون أقوى من حق الحاضنة

Yang bermaksud:-

“Sesungguhnya setiap yang menjaga dan yang dijaga (anak) mempunyai hak di dalam hal pemeliharaan tetapi hak yang dijaga (anak) lebih kuat daripada hak yang menjaga”.

[18] Berbalik kepada kes di hadapan kami ini, kami merujuk kepada alasan penghakiman Hakim Bicara yang pertama mendengar permohonan interim hadhanah tersebut. Kami berpuashati bahawa Hakim Bicara telah mempertimbangkan fakta kes dihadapannya sebelum mengeluarkan perintah bertarikh 11/11/2020. Dapatan Hakim Bicara tersebut adalah seperti berikut:-

“Berdasarkan fakta yang dikemukakan oleh P dan R anak tersebut berada bersama R. Pada peringkat ini pertukaran hak jagaan anak tersebut hendaklah dielakkan buat sementara waktu bagi mengelakkan kemudharatan kepadanya.....”

[19] Kami juga dapati Hakim Bicara semasa mengeluarkan perintah interim bertarikh 11/11/2020 telah membuat pertimbangan sewajarnya dalam menentukan hak jagaan anak tersebut memandangkan semasa keputusan dibuat, anak tersebut pada setiap masa dan material adalah bersama Pemohon.

[20] Walau bagaimanapun, semasa perintah interim kedua diputuskan iaitu pada 28/4/2021, kami dapati Hakim Bicara yang kedua tersebut telah tidak memberikan apa-apa alasan atau justifikasi kenapa memerintahkan hak jagaan sementara selanjutnya terhadap anak tersebut. Hakim Bicara tersebut juga mengeluarkan perintah tanpa menyatakan ianya tambahan atau pindaan kepada perintah interim terhadulu.

[21] Berdasarkan kepada ulasan kami di atas, maka kami bersetuju bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf sehingga menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak apabila membuat keputusan/perintah interim tanpa memberikan apa-apa alasan

atau justifikasi serta tidak merujuk kepada peruntukan-peruntukan yang berkaitan, sedangkan telah wujud perintah interim yang masih berkuatkuasa antara pihak-pihak yang sama. Oleh yang demikian adalah wajar untuk kami campur tangan terhadap perintah perintah interim bertarikh 28/4/2021 tersebut.

[22] Seterusnya, kami ingin memberikan panduan kepada Mahkamah bawahan, ketika membicarakan kes-kes permohonan interim agar meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta ringkas yang dibentangkan dengan berhemah dan persoalan undang-undang yang dikemukakan oleh pihak-pihak adalah teratur, kerana akhirnya Mahkamah akan merumuskannya dengan alasan-alasan padat kenapa sesuatu permohonan patut diberi atau tidak, berdasarkan fakta-fakta ringkas dan persoalan undang-undang tersebut.

[23] Berkaitan dengan isu lawatan pula, suka kami nyatakan bahawa bapa mempunyai hak untuk memastikan ia dapat menziarahi anaknya, supaya tanggungjawab bapa dapat tercapai dari segi mendidik dan mengajar anak tersebut. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz. 7, hal 7321 menyebutkan:

والحنابلة كالشافعية قالوا : ان اختار المميز أباه كان عنده ليلا و نهارا , ولا يمنع من زيارة أمه , ولا تمنع هي من تربيته . وان اختارها كان عندها ليلا , وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه .

Maksudnya: ‘Mengikut pendapat mazhab Hanbali dan juga mazhab al-Syafie: sekiranya anak yang mumayyiz memilih bapanya, maka ia bersama bapanya siang dan malam, dan bapa tidak boleh melarangnya bagi menziarahi ibunya, dan juga bapanya tidak boleh melarang ibunya merawat anak itu bila

anak itu sakit. Sekiranya anak itu memilih ibunya, maka anak itu bersama ibunya pada waktu malam, dan bersama bapanya pada waktu siang supaya bapa dapat mendidiknya dan mengajarkannya.'

Walau bagaimanapun, dapatan zahir kami daripada pandangan ulama' tersebut, bahawa isu yang dibincangkan adalah berkenaan hak menziarahi anak yang tidak berada di dalam jagaanya sahaja. Hak menziarahi dan hak lawatan tersebut tidak semestinya termasuk mendapat hak untuk bermalam.

[24] Demi kebajikan anak tersebut, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod kes no. 10400-038-0222-2020 dan 10100-028-0119-2019, **MAKA** Kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

1. Permohonan semakan oleh Pemohon **DITERIMA**.
2. Perintah Interim kes no. 10100-028-0119-2019 bertarikh 28/4/2021 **DIBATALKAN**.
3. Perintah Interim kes no. 10400-038-0222-2020 bertarikh 11/11/2020 **DIKEKALKAN**.
4. Prosiding kes induk hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah **DISEGERAKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor